

<제5장 취소소송의 심리.제1절 심리>

I. 심리의 의의

1. 개념

- 심리라 함은 법원이 소송 당사자의 주장과 증거를 통하여 사실 관계와 법률 관계를 파악하고 판결의 기초를 형성하는 일련의 재판 활동을 말한다. 이는 소송 요건의 적법성 여부를 따지는 요건심리와 청구 내용의 당부를 판단하는 본안심리를 포함한다.

2. 행정소송의 심리

- 행정소송의 심리는 일반 민사소송의 심리 원칙을 기본으로 하되, 행정처분의 공정력 등 행정 사건의 특수성을 고려한 행정소송법상 특유의 규정이 적용된다. 행정소송법 제8조 제2항은 민사소송법의 규정을 준용하도록 정하고 있으나, 행정처분 특유의 직권심리주의 강화 등을 통하여 실질적인 공정 확보를 도모한다.

II. 심리의 내용

1. 요건심리

- 요건심리라 함은 법원이 소송을 본안심리할 수 있는지 여부에 대하여 그 적법성을 직권으로 조사하는 것을 말한다. 요건심리의 대상은 취소소송의 소송요건인 원고격적, 피고격적, 협의의 소의 이익, 제소기간, 관할 법원, 행정심판 전치 요건(필요적 전치 시) 등이다. 요건심리 결과 소송요건을 결한 경우 법원은 본안심리를 하지 않고 각하판결을 선고한다.

2. 본안심리

- 본안심리라 함은 소송요건이 충족되어 소송이 적법하다고 인정된 경우, 원고의 청구 내용 자체의 당부 즉, 행정처분의 위법성 여부를 심사하는 것을 말한다. 취소소송의 본안심리 대상은 원처분의 위법성이며, 법원은 처분 당시를 기준으로 사실 인정과 법률 해석을 통해 처분의 취소 사유 존재 여부를 판단한다. 위법성이 인정되면 취소판결을, 인정되지 않으면 기각판결을 선고한다.

III. 심리의 범위

1. 불고불리의 원칙에 따른 범위

- 불고불리의 원칙은 법원이 당사자가 청구한 범위 내에서만 심판해야 한다는 소송법상 원칙이다. 행정소송에서도 이 원칙이 적용되어 법원은 원고가 청구한 취소의 범위를 넘어 판결할 수 없다. 다만, 취소 사유의 제한에 있어서는 행정소송법 제26조에 따른 직권심리주의가 적용되어 원고가 주장하지 않은 위법 사유라도 법원은 직권으로 조사하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

2. 재량문제에 따른 범위

- 재량문제에 있어서 법원의 심리 범위는 행정청이 재량권을 행사할 때 법률이 정한 한계를 일탈하거나 남용했는지 여부에 국한된다(행정소송법 제27조). 법원은 행정청의 재량 판단을 대신하여 자신의 판단으로 대체할 수 없다는 점이 특징적이다. 재량권 일탈·남용의 판단은 비례의 원칙, 평등의 원칙, 신뢰보호의 원칙 등 행정법의 일반원칙 위반 여부를 중심으로 심사한다.

3. 법률문제·사실문제에 따른 범위

- 법률문제는 처분에 적용된 법령의 해석 및 적용의 위법성 여부로서, 법원의 전적인 심사 대상이 된다. 사실문제는 처분의 기초가 되는 사실 인정의 객관성 및 정당성 여부이다. 행정소송의 심리 구조는 직권심리주의의 적용으로 인해 사실문제 심리에 있어서는 법원의 직권 조사 권한이 강화되며, 행정청이 제출한 처분 근거 자료의 신뢰성 등을 중심으로 심사한다.

IV. 심리의 절차

1. 심리에 관한 일반원칙

- 행정소송의 심리 절차에 관하여는 행정소송법 제8조 제2항에 따라 민사소송법의 규정이 준용되므로, 변론주의, 공개심리주의, 구술심리주의 등의 일반원칙이 적용된다. 다만, 행정소송에서는 직권심리주의의 존재로 인해 변론주의가 민사소송보다 완화된 형태로 적용된다.

2. 행정소송법상 특수한 소송절차

- 행정소송법상 특수한 소송절차로는 법원의 직권 조사 및 증거 수집 권한을 규정한 직권심리주의(제26조), 소송 경제를 위한 관련청구소송의 병합(제10조), 판결의 효력을 받는 제3자의 소송참가(제16조), 행정청이 보유한 처분문서 제출 명령 등이 있다. 이러한 특수 절차는 행정청과 국민 간의 실질적 소송 능력 격차를 보완하기 위한 취지이다.

V. 주장책임

1. 의의

- 주장책임이라 함은 당사자가 자신에게 유리한 사실을 주장하지 않아 불이익한 판결을 받게 되는 위험을 말한다. 행정소송은 직권심리주의의 적용으로 인하여 민사소송보다 주장책임이 완화된다. 법원은 당사자가 명시적으로 주장하지 않은 위법 사유도 직권으로 조사할 수 있기 때문이다.

2. 판례

- 판례는 행정소송에서 주장책임의 완화를 인정한다. 원고가 절차상 위법 사유를 명시적으로 주장하지 않았더라도, 법원은 기록 상 명백히 존재하는 위법 사유가 있다면 이를 직권으로 조사하여 취소 판결을 할 수 있다. 다만, 법원의 직권 조사 권한은 당사자의 변론을 보충하는 한도 내에서 행사되어야 하며, 청구 취지를 초월하여 판단할 수는 없다.

VI. 입증책임

1. 의의

- 입증책임이라 함은 어떤 사실의 존재 또는 부존재가 심리 결과 불명확할 때, 그 불명확함으로 인하여 불리한 판결을 받게 되는 위험을 말한다. 이는 증명책임이라고도 하며, 소송 결과에 직접적인 영향을 미친다.

2. 문제점

- 행정소송에서의 입증책임 분배 문제는 행정청이 처분 근거 자료나 정보를 독점하고 있어 국민 측이 입증에 어려움을 겪을 수 있다는 점에서 특수한 문제가 된다. 이로 인해 민사소송의 원칙인 법규요건분류설을 그대로 적용하기 어렵다는 주장이 제기된다.

3. 학설

- 입증책임 분배에 대한 학설 중 법규요건분류설은 처분의 위법성 요소는 원고가, 적법성 요소는 피고가 책임을 져야 한다고 본다. 이에 반해 권리근거규정설은 행정처분의 적법성 자체에 대하여 행정청이 책임을 져야 한다고 주장한다. 절충설 등 다양한 견해가 있으나, 일반적으로 법규요건분류설이 다수설의 입장을 취한다.

4. 판례

- 판례가 입증책임 분배에 관하여 어떠한 입장인지는 분명하지 않다. 행정소송에서의 입증책임도 원칙적으로 민사소송의 일반원칙(법률요건분류설)에 따라 당사자 간에 분배되어야 한다고 하면서도, 항고소송의 특성도 고려하여야 하는 것으로 이해한다.

5. 검토

- 입증책임 분배는 법규요건분류설을 기본으로 하되, 행정소송의 특수성을 고려하여 법원의 직권심리 강화 및 행정청의 적법성 입증책임 강화 방향으로 나아가야 한다. 특히, 행정청의 처분 근거 자료 제출 의무를 강화하여 원고의 실질적인 입증 곤란을 해소해야 한다.

6. 구체적 사례

- 과세처분 취소소송의 경우, 과세 처분의 요건 사실(세금 부과 대상이 되는 소득 발생 사실)의 존재에 대한 입증책임은 과세권자인 피고 행정청에 있다. 반면, 원고가 주장하는 특정 감면 요건 사실(비과세 요건 충족 사실)의 존재에 대한 입증책임은 그것을 주장하여 이익을 얻으려는 원고에게 있다.

VI. 결론

- 취소소송의 심리는 행정 사건의 특수성을 반영한 직권심리주의 등의 특례 규정이 적용되는 핵심적인 절차이다. 특히, 입증책임의 분배에 있어서 행정청에게 자신이 내린 처분의 적법성 입증책임을 부과함으로써 행정청과 국민 사이의 정보 및 능력 격차를 보완하고 국민의 권리 구제를 실질적으로 보장하는 방향으로 운영되고 있다.